

1500215-60.2020.8.26.0531

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. INVALIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1. A paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes por ter em depósito, em sua residência, a massa bruta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500215-60.2020.8.26.0531 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500215-60.2020.8.26.0531

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2125520/2020 - DEL.POL.ARIRANHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAILON BRUNO DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

MAILON BRUNO DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta da denúncia que no período da tarde do dia 21 de maio de 2020, na Rua Antenor de Genova, nº 405, bairro Cohab, na cidade de Ariranha, nesta Comarca de Santa Adélia, o denunciado tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções da droga cocaína, com peso líquido de 2,57g, e 09 (nove) porções da droga maconha, com peso líquido de 8,73g, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Consta, outrossim, que há alguns meses havia iniciado uma investigação para apurar o cometimento de tráfico de drogas pelo denunciado e, diante disso, a Autoridade Policial chegou a representar pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar (Procedimento nº 1500150-65.2020.8.26.0531) no endereço do denunciado. Contudo, expedida a ordem judicial 9fls. 23/24), o mandado não foi cumprido dentro

do prazo, decidindo o Delegado de Polícia aguardar o momento mais oportuno para a obtenção da prova. Ainda, segundo o apurado, no dia 21 de maio de 2020, agentes públicos de segurança deslocaram-se até o endereço do denunciado, realizaram campana e observaram ele chegando com uma bolsa preta e escondendo-a em um chiqueiro existente na sua residência. Então, procederam à sua abordagem e realizaram buscas no imóvel. No chiqueiro, dentro da bolsa, encontraram 07 (sete) porções da droga maconha, 05 (cinco) porções da droga cocaína e R\$20,00 (vinte reais) em espécie. Já no congelador da geladeira foram localizadas mais 02 (duas) porções da droga maconha.

A prisão em flagrante do réu foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 62/64).

O réu, devidamente notificado (fls. 113), apresentou, por meio de seu Causídico, defesa preliminar (fls. 104/108).

Não sendo vislumbradas as hipóteses autorizadoras da absolvição sumária, a denúncia foi recebida aos 12 de julho de 2021, designando-se audiência de instrução para o dia 23 de setembro seguinte, às 13h30m (fls. 258/259).

A denúncia foi recebida aos 02 de julho de 2020 (fl. 124) e, em atenção à decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus nº 592.415/SP do C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 118/123), o acusado foi colocado em liberdade aos 03 de julho de 2020 (fls. 131/134).

Em audiência de instrução realizada aos 03 de fevereiro de 2022, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais orais, pugnando pela condenação do acusado nos termos da exordial (fl. 216).

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais escritos, preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade por ilicitude da prova, sob o argumento de invasão domiciliar, pontuando a inobservância do prazo para cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão domiciliar e a inexistência de situação flagrancial, e emprego de coação moral (fls. 220/233). No mérito, sustentou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão ministerial deduzida na exordial é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Desde logo, registro que é caso de reconhecer a ilicitude de parcela da prova produzida e, no restante, operar a desclassificação da acusação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Porém, antes de elucidar os fundamentos desta conclusão, vejamos a prova oral colhida em juízo.

A testemunha Silvio Riva, policial civil, relatou em juízo que existiam diversas denúncias indicando que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas e, por essa razão, foi requisitado ao Juízo a expedição de mandado de busca e apreensão. Disse que na data da prisão avistou o réu descer o pasto com uma bolsa e a esconder no chiqueiro e, então, reunindo-se com os demais policiais, decidiram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Salientou que o acusado foi abordado no pasto e no chiqueiro, por indicação dele, encontraram a bolsa que continha parte da droga apreendida (porções de maconha e cocaína) e certa quantia em dinheiro. Esclareceu que, na casa do acusado, franqueada a entrada pelo irmão, encontraram mais algumas porções de maconha no congelador da geladeira. Segundo a testemunha, o réu confessou que vendia parte da droga para manter o próprio vício. O depoente ainda afirmou que o local era de intensa movimentação de usuários. No mais, questionado sobre o auto de busca e apreensão domiciliar de fls. 209, em que consta que toda a droga foi encontrada na casa do réu, a testemunha esclareceu que houve erro na confecção do documento, reafirmando que parte da droga foi encontrada no chiqueiro e outra parte na casa. Por fim, disse não saber se o mandado de busca e apreensão foi cumprido dentro do prazo estipulado.

O policial Marco Antonio Longo da Silva declarou que o acusado vinha sendo investigado em decorrência das denúncias anônimas atribuindo a ele a prática do tráfico de drogas e então foi representada a ordem de busca e apreensão domiciliar. Admitiu que o mandado de busca e apreensão não foi cumprido dentro do prazo de validade, pois aguardavam o melhor momento para seu cumprimento, pois precisavam da

cooperação de policiais de outra unidade policial. Na data da prisão, antes de se dirigirem à casa do réu para cumprimento do mandado de busca e apreensão, utilizaram-se do drone cedido pela DISE de Catanduva, que fotografou imagens do local, sendo possível observar que o acusado estava no chiqueiro. Deste modo, dirigiram-se inicialmente ao chiqueiro, onde encontraram o réu, mas ressaltou a testemunha que não acompanhou a sua abordagem. Depois de encontrada a droga no chiqueiro, foram até a casa do acusado, onde foi encontrada uma porção de maconha, apreensão que também não foi presenciada pelo depoente. Inquirida, a testemunha não soube responder se o mandado de busca e apreensão foi exibido ao réu e moradores da casa e disse não se recordar da elaboração do auto de busca e apreensão domiciliar. Ressaltou, mais uma vez, que não presenciou o encontro da droga na residência. A testemunha José Odair da Costa, ouvida como informante, contou que é pai do acusado e estava na casa quando um policial invadiu a residência, sem exibir qualquer mandado judicial. Em seguida, o delegado e outros policiais entraram, mas não exibiram o mandado de busca e apreensão, apenas mencionaram que estavam cumprindo uma ordem judicial. Na sequência, começaram a revistar a casa. Ressaltou que Mailon não estava na casa, estava no pasto tratando dos animais e, quando das buscas na residência, o réu já estava com os policiais, próximo à viatura. Confirmou, por fim, que foi encontrada uma porção de maconha na residência, mas não soube dizer onde, e ressaltou que seu filho é usuário de drogas.

A testemunha Malta Evanir Ignácio da Costa, tia do acusado, também foi ouvida sem o compromisso de dizer a verdade. Esclareceu que não reside no imóvel, mas que recebeu uma ligação de sua sobrinha, desesperada, dizendo que havia viaturas em sua casa e o pai (José Odair) havia saído para trabalhar. Ao chegar no local, deparou-se com policiais revistando a casa e, ao questioná-los sobre o que estava acontecendo, responderam que estavam cumprindo uma ordem judicial, mas não exibiram o mandado de busca e apreensão. Nesse momento, não viu o acusado. Os policiais disseram que o acusado estava detido, mas não o viu nas viaturas policiais. Não presenciou o encontro da droga, afirmando que não encontraram drogas na casa. Somente na delegacia, os policiais disseram que foram encontradas drogas, mas não mencionaram a quantidade e o local em que encontradas. Questionada, informou que o chiqueiro fica no pasto existente próximo à casa, mas que não faz parte da propriedade.

A testemunha de defesa João Vitor Gomes da Cruz informou que é colega do acusado e que no dia de sua prisão, Mailon esteve mais cedo em sua casa e disse que iria tratar dos porcos que ficam no pasto, o que fazia diariamente, na parte da tarde. Ressaltou que não presenciou a prisão do acusado, pois estava em sua casa.

A seu turno, o réu Mailon Bruno da Costa confirmou a propriedade de toda a droga apreendida, alegando, no entanto, que se destinava ao seu consumo pessoal. Contou que tinha ido ao chiqueiro tratar dos animais e quando estava na entrada do pasto, lavando os baldes, foi abordado por policiais. Segundo o acusado, os policiais disseram que tinham um mandado de busca e apreensão, que o réu estava preso e ordenaram que colocasse as mãos na cabeça. Contou que, ato contínuo, os policiais o pressionaram, fazendo ameaças contra sua família, e por isso acabou indicando a eles os locais em que estavam as drogas, parte no chiqueiro e outra parte na geladeira de sua casa). Informou que havia comprado o entorpecente naquele dia, na parte da manhã, e a escondeu no chiqueiro, levando apenas uma parte, a ser consumida, para sua casa. Esclareceu que o chiqueiro fica em um pasto pertencente ao município.

Essas são as provas.

Pois bem. Restou demonstrando em Juízo que parte da droga (5 porções de cocaína e 7 porções de maconha) foi apreendida em uma mochila escondida em um chiqueiro existente em um pasto pertencente à municipalidade, ao passo que o restante (duas porções de maconha) foi encontrada na casa do acusado. Nesse sentido o depoimento dos policiais ouvidos em juízo, versão, no mais, que foi confirmado pelo próprio acusado. Assim, resta sanado o equívoco observado no auto de busca e apreensão domiciliar de fl. 209, cuja leitura fazia presumir que todo o entorpecente havia sido encontrado na residência do réu.

Superada esta questão, deve ser reconhecida a ilicitude da prova com relação à

apreensão do entorpecente na residência do acusado, ante a irregularidade do ingresso dos policiais na residência. O mandado de busca e apreensão domiciliar não foi cumprido dentro do prazo de validade e, no mais, não existiam fundadas razões a indicar que dentro da casa ocorresse situação de flagrante delito a justificar o ingresso forçado dos policiais.

Nesse particular, ainda que os policiais mencionem que o acusado vinha sendo investigado em virtude de denúncias anônimas indicando suposto tráfico de drogas por ele realizado, o que teria ensejado a representação pela ordem de busca e apreensão domiciliar, fato é que não foram apresentados elementos idôneos a indicar que, na data em questão, dentro da casa ocorresse situação de flagrante delito. O policial Silvío relata que viu o acusado esconder uma bolsa no chiqueiro do pasto (que não fica na propriedade em que reside o réu), o que, por si só, não conduz à conclusão de que na residência havia drogas. Por sua vez, o policial Marco Antonio diz que foi feito um levantamento do local com um drone e que, diante das imagens, resolveu-se por dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, porém, as citadas imagens captadas pelo drone não vieram aos autos.

O que se vê, em verdade, é a apreensão fortuita de drogas durante cumprimento intempestivo de mandado de busca e apreensão domiciliar.

Do mesmo modo, a simples apreensão de drogas no chiqueiro, sem outros elementos a indicar a traficância realizada por Mailon naquela ocasião, não serviria de justificativa ao ingresso na residência do acusado sem ordem judicial. Não bastaria, para tanto, as alegadas denúncias anônimas de tráfico de drogas feitas em datas anteriores e sequer documentadas.

Além disso, a quantidade de drogas apreendida na mochila homiziada no chiqueiro (7 porções de maconha e 5 porções de cocaína) não se mostra expressiva e tampouco sugere, isoladamente, a finalidade de mercancia, revelando-se compatível com a tese de uso para consumo pessoal.

Enfim, não existiam fundadas razões da existência de estado flagrancial na residência do réu.

Vale lembrar que o E. Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade policial e de nulidade dos atos praticados".

E, nessa linha, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na ausência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, a regularidade do ingresso na residência do investigado, sem mandado judicial, fica condicionada à prova da autorização voluntária do morador, sem qualquer tipo de constrangimento ou coação, através de declaração escrita e assinada, indicando testemunhas do ato, sempre que possível, e registrada ainda por meio audiovisual. Por oportuno, cito a ementa integral de recente julgado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Vale anotar que a Sexta Turma estabeleceu o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação das provas colhidas nas investigações. 9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir: "1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência." 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP n. 132/2.20.0001682-3. Expeçam-se, também, alvará de soltura em benefício do paciente e, nos termos do art. 580 do CPP, da corré (HC nº 616.584-RS. STJ - 5ª Turma.

Ministro Ribeiro Dantas. DJ 30/03/2021).

Assim, a descoberta, a posteriori, de uma situação de flagrante (encontro das drogas) não passou de mero acaso. Nessas circunstâncias, conforme conclusões do precedente jurisprudencial citado, a legitimidade do ingresso dos policiais na residência do acusado estava condicionada à prova efetiva da autorização do morador, através de declaração escrita e registro em gravação audiovisual, o que não se observa no presente caso.

Houve, portanto, ingresso ilícito na residência do acusado e, por consequência, inaceitável a prova derivada dessa conduta (apreensão de drogas). Trata-se da aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. INVALIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1. A paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes por ter em depósito, em sua residência, a massa bruta total de 218,8g de cocaína e 13,5g de crack. 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 3. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. 4. Na hipótese, a delação anônima que ensejou a ação policial foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, sendo insuficiente, tão somente, o fato de ter sido encontrada droga na residência da acusada. Ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida mediante sua violação. A versão é a de que a paciente, sua genitora e padrasto teriam autorizado o ingresso dos policiais na residência. 5. Em depoimento, a genitora da acusada afirmou, contudo, que, "no dia dos fatos não estava em casa, pois levou o filho ao hospital. Ao chegar, encontrou a ré já dentro da viatura e foi informada por sua filha mais nova que os policiais invadiram o imóvel"; o padrasto da acusada, por sua vez, "confirmou que esteve no hospital com o filho e não presenciou os fatos", versões que divergem da apresentada pelos policiais. 6. Como já decidido por esta Corte, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [o genitor do paciente] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 7. Reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, obtida mediante invasão de domicílio desprovida de fundadas razões, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, deve a paciente ser absolvida da imputação de tráfico de drogas. 8. Concessão do habeas corpus. Absolvição da paciente, referente aos autos 1500288-22.2020.8.26.0599, oriundos da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Piracicaba. Expedição de alvará de soltura, se por aí não estiver presa. (HC 625.557/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021) Destaquei

Afinal, "não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima" (STJ, HC 655.637/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, decisão monocrática de 19/05/2021).

Por outro lado, não se observa qualquer irregularidade na apreensão do entorpecente escondido no "chiqueiro". E, nessa parte, a materialidade da infração está

demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/11), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo de constatação (fls. 35/37) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 84/86). Além disso, o próprio acusado confessou a propriedade da droga que, segundo afirmou, destinava-se a seu consumo próprio.

Ocorre que, a despeito dos argumentos do Parquet, as provas produzidas em juízo não indicam, de forma segura, que o entorpecente em questão era destinado à venda a terceiros. A quantidade de droga é pequena e as circunstâncias da apreensão não revelam o contrário. Com efeito, o acusado não foi surpreendido em ato de mercancia e, no mais, apenas foram mencionadas denúncias anônimas anteriores, que nem ao menos foram documentadas. E igualmente não há notícias e registro de diligências prévias que conferissem suporte àquelas denúncias.

Deveras temerária a condenação do acusado por crime tão grave com base tão somente em denúncias anônimas (repita-se, não documentadas) e em seus antecedentes criminais.

Nesse cenário, havendo dúvida razoável, mesmo que mínima, impõe-se, no caso, a desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga (art. 28, LD), em observância do *in dubio pro reo*.

A propósito, sobre o princípio da presunção de inocência e da regra probatória dele decorrente (*in dubio pro reo*), oportuna a lição de Renato Brasileiro:

“Por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência. Em outras palavras, recai exclusivamente sobre a acusação o ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar que o acusado praticou o fato delituoso que lhe foi imputado na peça acusatória. Como consectários da regra probatória, Antônio Magalhães Gomes Filho destaca: a) a incumbência do acusador de demonstrar a culpabilidade do acusado (pertence-lhe com exclusividade o ônus dessa prova); b) a necessidade de comprovar a existência dos fatos imputados, não de demonstrar a inconsistência das desculpas do acusado; c) tal comprovação deve ser feita legalmente (conforme o devido processo legal); d) impossibilidade de se obrigar o acusado a colaborar na apuração dos fatos (daí o seu direito ao silêncio). Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acerto penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o *in dubio pro reo*. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. O *in dubio pro reo* não é, portanto, uma simples regra de apreciação de provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusatória (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. Como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o *non liquet*.” (Manual de Processo Penal, Editora JusPodivm, 2ª Edição, 2014, pag. 50/51)

Por fim, fixada a responsabilidade penal do acusado pelo crime do art. 28, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Considerando que o acusado é reincidente, registrando condenação anterior por crime

de tráfico de drogas, aplicado a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses (art. 28, §4º, LD), em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial e assim o faço para CONDENAR o acusado como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser designada no Juízo da Execução.

Condeno o acusado ao pagamento das custas (Lei Estadual nº 11.608/03).

Não comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido (fl. 66), com o trânsito em julgado desta decisão, autorizo sua restituição ao acusado, mediante expedição de mandado de levantamento.

Após o trânsito em julgado:

i) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; ii) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação dos réus; iii) expeça-se guia de execução penal.

P.I.C.

Santa Adélia, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA